

第3節 原因において自由な行為

刑法
No117

H18-15

(配点：2)

月	日
月	日

次の【事例】の甲の罪責に関する後記の【記述】中の（ ）内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、被害者乙に罵倒されたことに憤激し、乙に対し、暴行の故意で、その顔をこぶしで殴打し、胸腹部を足で蹴る暴行を長時間にわたって継続的に加え、乙に顔面及び胸腹部打撲の傷害を負わせた上、最終的にその腹部を足で蹴った結果、内臓破裂の傷害を負わせて同人を死亡させた。甲は、暴行を開始した当初は責任能力に何ら問題はなかったが、暴行の開始後に飲酒し始め、その後も暴行を継続しながら飲酒し続けたため次第に酩酊し、顔面及び胸腹部打撲の傷害を負わせた時点では責任能力を有していたものの、犯行の途中で病的酩酊になり、乙の腹部を足で蹴って致命傷である内臓破裂の傷害を負わせた時点では、心神喪失の状態になっていた。

【記述】

「傷害致死の実行行為を、致命傷である内臓破裂の傷害を発生させた直接の原因である『乙の腹部を足で蹴った行為』であると解した場合には、行為と責任の同時存在の原則に（a. 例外を認めたとしても・b. 例外を認めない限り）、傷害致死罪の成立は認められない。これに対し、傷害致死の実行行為を、甲が心神喪失の状態となった原因である『飲酒行為』であると解した場合には、行為と責任の同時存在の原則の（c. 枠内で・d. 例外として）、傷害致死罪の成立を認めることが可能である。後者の見解は、（e. 間接正犯・f. 原因において自由な行為）として可罰性を認めるものであるが、この見解を採ると、（g. 間接正犯・h. 原因において自由な行為）において構成要件の結果を惹起することについての認識・予見のほかに、他人を道具として利用することについての認識・予見が必要とされているのと同様、自己を道具として利用することについての認識・予見が必要と解される。この事例において、甲は、飲酒し始めた時点で既に乙に対する憤激から暴行を開始しており、その後も憤激が冷めることなく暴行を継続しながら飲酒し続けているのであるから、自らが心神喪失の状態と（i. なることなく・j. なった後も）乙に対する暴行を継続することについての認識・予見があったと解される場合もあり、その場合には傷害致死罪が成立すると思われる。」

1. a c e h i 2. a d f g j 3. b c f g j 4. b d e h i
5. b d f g j

No117

原因において自由な行為

正答率

H18-15

正解

3

88%

原因において自由な行為とは、ある違法行為が責任無能力又は限定責任能力の状態でなされた場合であっても、その責任無能力等の状態が行為者の責任能力ある状態における行為によって自ら招いたものであるときは、当該違法行為に対し、完全な責任を問うことができるとする法理である。

a・bの選択 b

行為と責任の同時存在の原則とは、責任能力は実行行為の時に存在しなければならないという原則である。本問事例の乙の「腹部を足で蹴った行為」のような責任能力を欠く結果行為を実行行為とすれば、責任が否定されて犯罪は成立しないというのが率直な帰結である。しかし、行為と責任の同時存在の原則を修正し、例えば、責任能力は具体的犯行時にはなくても、無能力状態を有責に招いた原因行為時に存在していれば責任非難は可能であると解して、原因において自由な行為の可罰性を説明することは可能である。すなわち、本件において責任能力を欠く結果行為を実行行為としても、行為と責任の同時存在の原則を修正すれば、傷害致死罪が認められることになる。したがって、「b. 例外を認めない限り」が正しい。

c・dの選択 c

本問事例の『飲酒行為』のような原因行為を実行行為とすると、飲酒行為の時点では責任能力を有していたのであるから、責任能力は実行行為の時に存在しなければならないという行為と責任の同時存在の原則を遵守しているといえる。すなわち、行為と責任の同時存在の原則を修正することなく、傷害致死罪が認められることになる。したがって、「c. 枠内で」が正しい。

e・fの選択 f

g・hの選択 g

本問記述の後者の見解は、原因において自由な行為の可罰性を間接正犯類似説で説明するものである。すなわち、間接正犯類似説とは、行為者が故意又は過失によって自分自身を心神喪失に陥れ、その状態における身体的動静を道具のように利用して犯罪を実現するのが原因において自由な行為であるから、他人を道具として利用する間接正犯に類似するものとして捉える見解である。すなわち、行為者に責任能力のあった時期における、自由な意思状態での原因行為にその実行行為性を認め、その行為に、自己を責任無能力状態に陥らせ、その状態での身体的動静によって一定の犯罪を実現させる現実的危険性が含まれているときは、それを実行行為として捉えるのである。したがって、「f. 原因において自由な行為」「g. 間接正犯」が正しい。

i・jの選択 j

本問記述内で後者の見解である間接正犯類似説は、自己を道具として利用することについての認識・予見が必要と解されるとされている。このような立場を本問事例にあてはめると、自らが心神喪失の状態となることがなかった場合、39条1項は適用は問題なく否定され、傷害致死罪が成立するのは当然であり、その場合に乙に対する暴行を継続することについての認識・予見があったとしても、自己を道具として利用することについての認識・予見があったとはいえない。これに対し、自らが心神喪失の状態となった後も乙に対する暴行を継続することについての認識・予見があった場合には、自己を道具として利用することについての認識・予見があったといえるので、間接正犯類似説からも傷害致死罪の成立を認めることができる。したがって、「j. なった後も」が正しい。